

1508377-45.2021.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

#### SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508377-45.2021.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2263002/2021 - DEL.POL.VARGEM, 14848648 - DEL.POL.VARGEM, 2263002 - DEL.POL.VARGEM

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FELIPE PEREIRA FRANCO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

LUIZ DIEGO DE MOURA LIMA e FELIPE PEREIRA FRANCO foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 05 de setembro de 2021, na rua Augusto Bartolo, 001, Pesqueiro do Zé - Rio Acima, cidade de Vargem, nesta Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, tentaram subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens

pertencentes à vítima José Aparecido da Silva, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. Recebida a denúncia aos 04 de outubro de 2021 (fl. 150), os acusados foram citados e apresentaram suas respostas à acusação (fls. 181/196, 259 e 263/264).

Ratificado o recebimento da inicial (fls. 270), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas da acusação e uma da defesa. Ao final, promoveram-se os interrogatórios dos acusados (fls. 349).

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência parcial da ação penal, por entender que as provas carreadas aos autos autorizam somente a condenação de Luiz Diego (fls. 368/374).

A defesa postulou a absolvição embasada na ausência de provas das autorias e na fragilidade dos depoimentos colhidos, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de ameaça (fls. 414/419).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação é parcialmente procedente.

Com efeito, a autoria em relação ao acusado Felipe não foi devidamente comprovada. Durante seu interrogatório ele negou qualquer envolvimento nos fatos.

Felipe declarou que conhece a vítima porque frequentava o pesqueiro de sua propriedade. Explicou que na época dos fatos perdeu seu aparelho celular e, em contato com a vítima, ela lhe informou que o celular estaria na posse de Luiz Diego (coacusado). Diante disso, foi até a casa de "Diego" e lhe questionou sobre o seu aparelho.

Acrescentou que durante conversa com Diego, resolveram se dirigir até o pesqueiro e conversar com a vítima. Naquele dia, então, foi com sua motocicleta até lá, levando em sua garupa o coacusado. Assim que chegaram, parou sua motocicleta na frente do pesqueiro, enquanto Luiz Diego desceu e procurou pela vítima.

Salientou que pouco tempo depois, observou a vítima e o coacusado discutindo e, em seguida, a vítima com um pedaço de madeira na mão, fazendo com que Luiz Diego dali fugisse. Finalizou, informando que a vítima lhe confidenciou que o coacusado estava na posse de uma arma.

Eis suas palavras:

D: (...) Cheguei no domingo, falei pro Zé, sabem quem tá vendendo um celular aí? Que já tinham me falado. Sei. É um rapaz que chama Diego. Eu nem conhecia. Eu falei assim, mas onde eu posso encontrar ele? Ele falou, lá no campo. Aí eu fui no campo, olhei, eu rodei tudo e não encontrei. Aí retornei até no pesqueiro de novo. Falei, oh Zé, não encontrei. Foi onde ele passou o endereço e o número da casa. Retornei até a casa. Chamei. Achei o endereço. Chamei no portão, saiu uma senhora. Eu perguntei pra senhora se havia um Diego morava ali. Ela falou que tinha. Eu mandei se tinha como chamar ele pra mim. Aí foi e chamou. Aí de repente ele veio, realmente não foi a pessoa que eu tinha dado carona. Aí perguntei pra ele, o Zé tá falando que você está vendendo um celular. Ele falou assim, eu não tô vendendo celular. Eu falei assim, ele tá falando que você está vendendo um celular. Tem certeza? Ele falou, não. Eu retornei até no pesqueiro de novo. Falei pro Zé. Falei assim, ó Zé não foi ele que eu tinha dado carona, ele falou que não tá vendendo celular não. Ele falou assim, não, é ele mesmo que está vendendo celular seu, ele roubou o celular seu. Aí eu voltei até na casa dele de novo. Estava desesperado pelo celular. Que eu tinha muita coisa importante no celular. Coisas pessoais. Contas no banco. Coisa até do meu trabalho. No caso o meu trabalho. Eu retornei. Aí ele não tava na casa. Ele tava no campo. Aí eu chamei, eu falei, ó Diego, o Zé tá afirmando que você tava vendendo um celular por cinquenta reais. Ele falou, vamo lá então pra conversar com o Zé, porque ele tá acusando eu de ter roubado o celular. Aí foi, a gente desceu de novo. Cheguei no pesqueiro. Parei a minha moto ali em frente, debaixo do pé de manga e subi primeiro. E ali tinha uma pessoa que estava pescando, aí eu parei pra conversar com essa pessoa, enquanto o Diego foi conversar com o Zé. Aí não deu pra entender o que eles estava discutindo. Eu fiquei um pouquinho afastado de onde eles estava conversando. Aí só vi a hora que saiu com o pau. Eu falei, ele tá vindo com o pau ali. Aí ele foi descendo normal, o Diego,

andando normal. Aí o Zé aparece com um cabo de enxada na mão atrás dele. E do estacionamento não dá pra ver o que eles discutiram ou brigaram. Aí de repente volta o Zé. Volta o Zé falando, ele tava armado. Mas não relatou que tipo de arma que era. Só falou que ia fazer a denúncia. Fazer o boletim de ocorrência. Eu falei, pode fazer Zé, que eu vou fazer do celular, porque tem muitas coisas pessoais no meu celular.

J.: O senhor ficou na moto e o Diego foi conversar com ele?

D.: Não. Eu subi primeiro. A gente subiu a escadinha. Enquanto ele foi lá, eu fiquei conversando com um rapaz que estava pescando ali, porque no outro dia...

J.: Então o senhor ficou dentro do estabelecimento lá?

D.: Não. Lá é fora.

J.: É ali. E o Diego conversou com ele onde?

D.: Conversou na mesa de bilhar.

J.: E ele saiu correndo atrás do Diego?

D.: Não. O Diego saiu andando normal. Desceu a escada normal, sentido indo embora. E depois veio o Zé atrás. Depois não dá pra ver que tem um é de limão e tampa a visão do estacionamento.

Sua versão não pode ser contrariada, uma vez que inexiste provas que indiquem com segurança sua autoria. Senão vejamos.

A vítima José confirmou que conhecia Felipe porque algumas vezes ele havia frequentado seu pesqueiro. Declarou que somente Luiz Diego adentrou em seu estabelecimento durante o roubo e que Felipe permaneceu do lado de fora.

Pontue-se que José nada acrescentou sobre o possível envolvimento de Felipe no episódio, declarando apenas que durante toda a ação ele permaneceu próximo a uma árvore existente no pesqueiro.

No mesmo sentido foram as palavras da testemunha Eduardo, que presenciou todo o evento. Ele ratificou a versão de Felipe no sentido de que somente o coacusado Luiz Diego adentrou no estabelecimento, enquanto Felipe permaneceu do lado de fora.

Por sua vez, o PM Ediceu nada apresentou de concreto quanto a autoria imputada a Felipe, apenas trazendo relatos de acordo com a versão apresentada pela vítima durante o atendimento da ocorrência policial.

Acrescente-se, também, que o depoimento da testemunha de defesa corroborou com a versão de Felipe.

Leide disse que na ocasião dos fatos Felipe foi até a casa de Luiz Diego para questioná-lo sobre o furto de seu aparelho celular. Na sequência, ambos seguiram até o pesqueiro.

Por fim, o coacusado Luiz Diego narrou que Felipe não participou da discussão que teve com a vítima, bem como de que ele ficou na frente do estabelecimento.

Portanto, a prova colhida é insuficiente a assegurar a autoria de Felipe no delito em pauta, tanto é que a própria acusação pugnou nesse sentido.

Por outro lado, a autoria de Luiz Diego está plenamente comprovada, não obstante as escusas inconvincentes do acusado, que em seu interrogatório negou qualquer participação no evento, argumentando que naquele dia somente teria ido ao pesqueiro para questionar a vítima, uma vez que ele teria lhe incriminado de subtrair o celular de Felipe.

Declarou, ainda, que de fato levou consigo uma arma de brinquedo, em razão de desavença anterior com a vítima.

No mais, ele apresentou informações desencontradas e sem respaldo nos autos, sem apresentar justificativa por quais motivos poderiam a vítima e as testemunhas querer incriminá-lo injustificadamente.

A par disso, as provas colhidas nos autos certificam sua autoria.

A vítima José Aparecido afirmou que na data dos fatos Luiz Diego chegou no pesqueiro e, na posse de uma arma, anunciou o assalto dizendo: "você perdeu".

Diante disso, munuiu-se de um porrete visando contê-lo. Explicou que durante a ação o acusado puxou o gatilho da arma várias vezes, porém a munição picotou e ele dali fugiu sem subtrair qualquer bem.

Declarou, também, que Luiz Diego já frequentou o pesqueiro algumas vezes, motivo pelo qual o conhecia. Ao final, informou que após os fatos apresentou na Delegacia de Polícia as imagens obtidas pelas câmeras de segurança existentes no local,

possibilitando aos policiais a correta identificação do agente.

Vejamos suas palavras:

J.: Os dois chegaram a pé e daí?

D.: Aí um ficou atrás de uma pilastra, da viga, o Felipe. O Diego encostou do lado do balcão e falou que eu tinha perdido, e mostrou a arma.

J.: Mostrou a arma pro senhor?

D.: É o Diego, e o Felipe... (inaudível)

J.: Falou que era um assalto?

D.: É. ele falou, você perdeu de novo. Já tinha me roubado um dia antes, o Diego.

J.: Por isso que ele falou "perdeu de novo"?

D.: É. Ele falou que perdeu de novo. Um dia antes ele já tinha levado dinheiro, um dia antes.

J.: E daí? O que o senhor fez quando ele falou isso?

D.: Aí quando eu vi as crianças debaixo do revólver lá, meu peguei um porrete e saí entendeu? Saí pra atropelar ele entendeu? Aí ele saiu puxando o revólver, foi batendo o revólver até lá no meio da turma, entendeu?

J.: Ele tentou disparar?

D.: Não. Ele foi batendo. A bala foi picotando.

J.: Batendo o quê o senhor quer dizer? Ele apertou o gatilho?

D.: É foi puxando o gatilho, mas a arma chegou a picotar, entendeu? Até a civil falou que chegou a marcar, a picotar pra trás, entendeu?

J.: Só que não saiu tiro?

D.: Não, não saiu, graças a Deus não.

J.: E daí o que que o senhor fez?

D.: Aí eu voltei e tentei ligar pra polícia, só que lá não atende o telefone que tem só uma viatura lá na Vargem.

J.: Aí como não saiu o tiro eles fugiram, foi isso?

D.: Fugiu. Um fugiu de lá de moto e o outro de a pé.

Suas palavras são confirmadas pela testemunha Eduardo. Ele narrou que naquele dia estava no pesqueiro quando ali adentrou o acusado. Disse que ouviu uma discussão entre a vítima e Luiz Diego, bem como afirmou que visualizou o acusado na posse de uma arma de fogo. Mencionou que a vítima se apropriou de um pedaço de madeira e correu atrás do indivíduo, que fugiu na sequência. Finalizou mencionando que naquela ocasião a vítima lhe narrou que o acusado estava naquele local para lhe roubar.

Por fim, o PM Ediceu relatou que foi acionado para atender uma ocorrência de roubo em um pesqueiro. Contou que antes mesmo que se dirigisse até o local, encontrou-se com a vítima na base da polícia militar, oportunidade em que ela lhe narrou a tentativa de roubo ocorrida em seu estabelecimento, afirmando que naquele dia o acusado havia chegado ao local e apontado uma arma de fogo para ele, bem como efetuado uma tentativa de disparo, porém a arma falhou, obrigando o agente a fugir do local.

Anote-se que, em Juízo, a vítima José reconheceu com segurança Luiz Diego como o agente da tentativa de roubo perpetrada no pesqueiro.

Ora, a palavra da vítima foi segura em detalhar as ações sofridas e a conduta do acusado, merecendo credibilidade.

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa para identificar o autor do assalto".

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si".

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas de todos os réus. (TJSP; Apelação Criminal 0036653-26.2015.8.26.0050; Relator (a): Luís Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

A par disto, o relatório elaborado pelo setor de investigação (fls. 18/19) corrobora com a certeza da autoria.

Nesse sentido:

Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Recursos da defesa. 1. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento das rés Janaína e Dayane pela vítima. Depoimentos firmes dos investigadores de polícia confirmando os procedimentos de investigação que levaram à identificação de todas as acusadas que foram gravadas através de câmeras de segurança instaladas em via pública. Confissão das acusadas Janaína e Dayane. Regime inicial fechado mantido. 4. Recurso da apelante Camila a que se nega provimento. Parcial provimento do recurso das apelantes Janaína e Dayane. (TJSP; Apelação Criminal 1531752-96.2019.8.26.0050; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Majorante bem delineada. Arma branca (faca) apreendida nos autos. Inviável a pleiteada desclassificação. Condenação bem lançada. Dosimetria. Mantidos os aumentos aplicados nas duas etapas iniciais em razão, respectivamente, dos péssimos antecedentes e da multirreincidência, que justificam a fixação do regime inicial fechado. Artigo 33, §§2º, alínea b, e 3º, do Código Penal. Sentença mantida. Pedido de aplicação da detração. Matéria afeta ao Juízo da Execução RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500243-17.2020.8.26.0567; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Por fim, não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as demais provas colhidas.

Diante de todas estas circunstâncias em torno do acusado, que não se escusou de maneira convincente ante o conteúdo das provas existentes, deve ser considerada certa sua autoria.

No mais, as alegações da defesa carecem de razão. A prova testemunhal foi plena e está de acordo com o conjunto amealhado.

A materialidade do delito está evidente diante do conjunto probatório elencado. O documento de ocorrência (fls.08/09), o relatório do setor de investigação (fls. 18/19), o auto de reconhecimento (fl. 14), bem como o depoimento das testemunhas certificam a subsunção dos fatos ao tipo denunciado.

Por fim, o delito não se consumou em virtude da imediata reação da vítima, que rechaçou a ação criminosa e impediu que o acusado subtraísse qualquer bem do local, circunstância esta, alheia a sua vontade.

Quanto à causa de aumento descrita no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal (A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), é evidente que ela incidirá.

A vítima foi firme em detalhar o emprego de arma de fogo. Ademais, é desnecessária a apreensão da arma para a incidência desta causa especial.

"Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado seu poder vulnerante".  
"A não apreensão da arma não impede o reconhecimento dessa qualificadora, desde que sua utilização reste demonstrada por outros meios e tenha ela atuado no espírito da vítima como fator inibidor de eventual reação".

E mais:

ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. Recursos defensivos. PRELIMINAR. Pedido de produção de prova (MARCOS) conhecido como questão prejudicial e rejeitado. MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Preservação das causas de aumento, porque amplamente comprovadas pelo acervo. Irrelevância da não apreensão da arma de fogo. DOSIMETRIA. Afastamento do acréscimo operado nas bases de FRANK e GILVAN. Inteligência da Súmula/STJ, nº 444. Redução das penas de GILVAN e MARCOS. Correção de erro aritmético. Regime fechado obrigatório. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. Impertinência. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PARCIAL PROVIMENTO. (TJSP; Apelação Criminal 0011022-90.2015.8.26.0176; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020).

Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Ausência de fragilidade probatória - Condenação mantida. Artigo 226 do Código de Processo Penal - Mera recomendação - Inobservância que não tem o condão de macular o feito - Preliminar rejeitada. Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Dupla majoração - Gravidade concreta do delito - Possibilidade - Regime fechado - Pena superior a oito anos. Concurso formal - Reconhecimento - Possibilidade - Em uma única ação foram vulnerados patrimônios diversos - Recurso da Defesa improvido e o do Ministério Público provido para aplicar o artigo 70 do Código Penal. (TJSP; Apelação Criminal 1501034-20.2019.8.26.0082; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Boituva - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Não deve prosperar a alegação da defesa de que a arma utilizada poderia ser um simulacro e, com isso, não se aplicaria a majorante. Primeiro porque o instrumento provocou o efeito intimidante de uma arma. Ao depois, as testemunhas e vítimas nada disseram no sentido de que poderia ser um simulacro, pelo contrário, a vítima afirmou que durante a ação, o acusado acionou o gatilho, porém a arma falhou e a munição picotou.

Por outro lado, ante a absolvição de Felipe, a causa de aumento descrita no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal: "se há concurso de duas ou mais pessoas", não incidirá.

Concluída a fundamentação, passo à dosagem da pena onde devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliente que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes não recomendam exacerbação. Sua conduta social e personalidade não podem ser avaliadas ante a ausência de elementos seguros nos autos.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade.

Ausentes as circunstâncias judiciais que deveriam elevar à exacerbação da pena-base, fixo-as em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar. Na terceira etapa, reconhecida a causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo em comento (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), suas penas serão elevadas em 2/3 (4 anos + 2/3 = 6 anos e 08 meses de reclusão/10 dias + 2/3 = 16 dias-multa).

Por fim, diante do pequeno percurso percorrido pelo agente, as penas serão

diminuídas em 2/3 em razão da tentativa (6 anos e 08 meses - 2/3 = 2 anos, 2 meses e 20 dias/ 16 dias - 2/3 = 05 dias).

Para início do cumprimento da pena fixo o regime fechado ante a gravidade da infração.

"O regime fechado é o único compatível com o início do cumprimento de pena imposta ao autor de roubo, uma das mais intranquilizadoras expressões da criminalidade nos tempos correntes".

Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO ERESP N.º 961.863/RS. AUMENTO DA REPRIMENDA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, ACIMA DA RAZÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MERA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO (OBJETIVO). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 443/STJ. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SÚMULAS N.os 440 DESTA CORTE, 718 E 719, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM PARTE. 1. A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo uso na ação delituosa. Precedentes. 2. Consoante dispõe o enunciado da Súmula n.º 443 deste Tribunal Superior: "[o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Desse modo, impõe-se a aplicação do quantum de aumento, em razão das majorantes do roubo, no grau mínimo legal, visto que a fração aplicada - 3/8 (três oitavos) - foi fundamentada, exclusivamente, em critério matemático, sem base em elementos concretos, entendimento que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes. 4. Inexiste violação das Súmulas n.os 440 desta Corte Superior, 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal, quando a fixação do regime prisional é baseada na gravidade concreta do delito. No caso, considerou-se, para a fixação do regime inicial fechado, a audácia do Paciente, que praticou os delitos, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em via pública e à noite, circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta delituosa. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a fração da majorante, aplicada na terceira fase, de 3/8 (três oitavos) para 1/3 (um terço), redimensionando as penas, nos termos explicitados no voto. (STJ - HC: 459546 SP 2018/0175677-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019). APELAÇÃO. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) desclassificação para o crime de furto; b) fixação da pena base no mínimo; c) reconhecimento da atenuante da confissão e compensação com a agravante da reincidência; d) fixação de regime diverso do fechado. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e do policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena corretamente aplicada. 3. Regime prisional fechado. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-SP - APR: 15072571220188260506 SP 1507257-12.2018.8.26.0506, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 11/11/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/02/2020) Apelação. Crime de roubo. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma, fixando o regime fechado para início do desconto da pena privativa de liberdade. Recurso da Defesa visando: (i) afastar o emprego da majorante; (ii) o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda. 1. A ausência de exame pericial na arma não obsta a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, par.2º, I, do Código Penal. 2. Os dados empíricos da causa traduzem um grau de culpabilidade que impõem o regime inicial

fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso defensivo desprovido. (TJ-SP - APL: 00023261220148260108 SP 0002326-12.2014.8.26.0108, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 26/01/2017, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/01/2017).

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese.

Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo:

20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014)

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de:

A) ABSOLVER FELIPE PEREIRA FRANCO, qualificado nos autos, da imputação do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal;

B) CONDENAR LUIZ DIEGO DE MOURA LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua condição econômica.

A gravidade da infração e a pena aplicada impedem qualquer forma de substituição de pena privativa de liberdade por outras penas, de diferente espécie, como também, impedem a suspensão condicional da pena.

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavaski, DJe de 18/12/2014).

Saliente-se, ainda, que mesmo diante da atual circunstância, a par da recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que sugere a adoção de algumas providências pelos magistrados a fim de resguardar a saúde dos presos em face da pandemia gerada pelo Coronavírus, ela não o vincula, assim como não justifica por si só o pedido da defesa para conceder ao acusado o direito de apelar em liberdade com consequente liberdade provisória.

Deve se destacar que a Secretaria de Administração Penitenciária adotou medidas



criteriosas para combate à pandemia nas unidades prisionais, como a suspensão de visitas, higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo de risco, imediato isolamento dos casos suspeitos etc. ; não bastasse, o atendimento hospitalar ao preso com suspeita de contaminação é imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere do que aquele ofertado à população, em face da atual situação da malha hospitalar pública segundo registrado reiteradamente na imprensa. Infelizmente, todos os cidadãos do mundo estão expostos ao problema.

No mesmo sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"...Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco..." (STJ AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

E mais:

HABEAS CORPUS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO REGIME E À PENA FIXADOS NA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO - Insurgência contra decisão mantida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora - PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - Inexiste constrangimento ilegal em decisão que denega o direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" NÃO FORMULADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - Necessária a análise do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2055190-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Habeas Corpus. Roubo, tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - Condenado - Pedido de que o paciente possa apelar em liberdade - Inadequado - Réu respondeu preso o processo - Presentes circunstâncias que recomendam sua manutenção no cárcere - Prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus - Inadmissibilidade - Em primeiro lugar, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar - Ainda, não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do estado de saúde do paciente que possibilite a prisão domiciliar, ainda que ele tenha problemas respiratórios - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2147261-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento 16/08/2020; Data de Registro: 16/08/2020)

HABEAS CORPUS - Roubo majorado - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Apelo em liberdade - Sentença que indeferiu essa pretensão - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ nº 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado - Inexistência de excesso de prazo na condução do feito na origem -

Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2099550-36.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020).

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança Paulista, 23 de fevereiro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO  
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA